

1500765-68.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500765-68.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500765-68.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2093278/2022 - 02º D.P. AMERICANA, 24095533 - 02º D.P.

AMERICANA, 2093278 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS ELIAS ANTONIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

JONATAS ELIAS ANTÔNIO está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, acusado de em 05 de abril de 2022, por volta das 12 horas, na Avenida Doutor Antônio Lobo, 55, Centro, nesta cidade, trazer com ele, com a finalidade de tráfico, vinte e nove invólucros plásticos fechados por nó encerrando porção de material sólido petrificado, com massa de 4,9 gramas, na qual foi detectada presença da substância cocaína, além de R\$ 98,10 em dinheiro, substâncias estas causadoras de dependência química, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação. A denúncia foi recebida em 26 de maio de 2022 (fls. 129/130). Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e interrogado o réu. Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação pugnou pela procedência da denúncia, provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 160/162). A Defesa, em memoriais, requer a absolvição por falta de provas. Contra o réu pesariam apenas suposições, não possível ao réu vender drogas no horário (meio dia), em pleno terminal rodoviário. O local, segundo policiais, seria comum para uso e compra de drogas, não venda. O réu teria comprado, para consumo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. A quantidade de drogas era ínfima, pesavam 4,9 gramas. O acusado era morador de rua, usuário de drogas. Seu cachimbo foi encontrado próximo da bolsa que portava. Para o caso de condenação, pena mínima, com aplicação do redutor (art. 33, §4º) no patamar máximo. Regime brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, enfim, concessão da gratuidade, detração da pena e recurso em liberdade (fls. 165/174).

É o relatório.

DECIDO.

O réu alegou, na fase policial, que era usuário de crack desde o ano de 1993 e comprou 28 papелotes de crack, por duzentos e cinquenta reais, para uso próprio. Comprou na linha férrea, de desconhecido. Foi abordado em seguida. O dinheiro era resultado de trabalho autônomo, de limpeza. Não traficava - fls. 04. No interrogatório judicial, alegou que estava do lado de fora do 'terminalzinho'. Tinha acabado de fazer a compra da droga, ganhou uma pedrinha de brinde e o rapaz devolveu o troco, quando a viatura se aproximou. Retornou até a sua bolsa e guardou os entorpecentes, enquanto o seu cachorro o esperava, comendo ração. Os guardas o abordaram, não reagiu. Os rapazes que o atenderam correram para dentro da linha férrea. Era usuário de drogas, nunca foi traficante. Morava nas ruas. Foi condenado pela prática de furtos, nunca por tráfico. Não entregou nada para os dois rapazes, na verdade recebeu deles as drogas. Estava dentro do terminal, aguardava a chegada dos entorpecentes, que vinha dentro da linha do trem. Quando as drogas chegaram, os homens o chamaram de 'Alemão' e perguntaram a quantidade que queria. Fez a sua compra, estava de costas para a Avenida Antônio Lobo, encostado no alambrado. Quando olhou para trás, avistou a viatura e os vendedores correram. Retornou até o local em que havia deixado a sua bolsa e guardou os entorpecentes. Foi abordado, os guardas encontraram uma unidade em sua boca, que ganhou de brinde por ter comprado uma maior quantidade de entorpecentes. Veio da casa do seu pai, no Ceará. Tinha duas irmãs, moram no bairro Antônio Zanaga e na cidade de Santa Bárbara d'Oeste. Estava em situação de rua, trabalhava limpando calçadas, na área central. Não sabia o nome dos vendedores, apenas os conhecia pelo vulgo 'Neguinho' e 'Marquinho'. Pagou a quantia de R\$ 280,00 pelas drogas. Entregou R\$ 300,00 e recebeu R\$ 20,00 de troco. Devia R\$ 10,00 para eles. Confirmava possuir vinte e oito porções de crack, dentro da sua bolsa.

A versão não convence.

O guarda municipal Davi Fernando Elias da Silva se lembrou de que patrulhavam pela área central, nas proximidades da linha férrea, quando avistaram o Jonas caminhando em direção ao alambrado. Na ocasião, ele entregou alguma coisa para dois rapazes. No momento em que a viatura se aproximava, os dois rapazes que estavam do outro lado do alambrado saíram correndo. Jonas foi abordado. Durante a revista, localizaram R\$ 20,00 no bolso da vestimenta e uma pedra de crack na boca do acusado. Indagado, disse ser dependente químico, negou ter comercializado drogas. Perto do abordado, havia uma bolsa. O acusado disse que a mochila era sua e a vasculharam. O GCM Cauê localizou em seu interior algumas peças de roupas, chinelos e envelopes, com mais 28 papелotes de crack, além da quantia de R\$ 78,00. O réu falou que 'estava no trecho', na rua. Em seguida, apresentaram o acusado na Central de Polícia Judiciária. Não localizaram apetrechos na bolsa, apenas um cachimbo no chão, perto do suspeito. Nada foi perguntado sobre o cachimbo e nem o acusado

afirmou que era dele. Tratava-se de local frequentado por muitos usuários de drogas. Não conhecia o acusado, mas o seu colega de farda, que trabalhava nas ruas há mais tempo, já o conhecia.

Cauê Spagnol Silva, outro guarda municipal, ratificando a versão do colega, relatou que realizavam patrulhamento preventivo, estavam no Mercado Municipal. Ao sair dali, passaram pelo terminal metropolitano, situado ao lado, quando observaram o Jônatas. Ele estava encostado na grade, que divide a linha férrea, do lado do terminal metropolitano. Perceberam que do outro lado, havia duas pessoas, Jônatas estava trocando algo com eles. Ao avistar a viatura, os dois rapazes não identificados se evadiram, pelo lado da linha férrea, enquanto Jônatas rumava pelo lado do terminal. Ele foi abordado e revistado, localizaram nas mãos do acusado a quantia de R\$ 20,00, em notas de R\$ 2,00, além de uma pedra de crack, escondida em sua boca. Havia uma bolsa preta ao lado dele. Indagado, Jônatas informou que a mochila era dele. Realizaram buscas, dentro dela tinha algumas roupas, documentos pessoais, a quantia de R\$ 78,10 e 28 porções de crack. Indagado, o acusado disse que era morador de rua e que pagou a quantia de R\$ 250,00 pelos entorpecentes, destinados para consumo próprio. Diante disso, ele foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária para deliberações da autoridade policial.

Não se recordava se o réu tinha algum apetrecho para uso de entorpecentes, como cachimbo, dichavador ou outro equipamento.

O réu foi visto em ponto de tráfico de drogas, sem embargo de a Defesa alegar que o local seria propício para consumo e compra, não venda. Por óbvio, se há compra, há alguém que vende.

Na hipótese, o réu estava junto à grade, no terminal, trocando algo com pessoas, atitude típica de tráfico. Imediatamente abordado, tinha uma porção de crack na boca e, algo distante dele, na mochila que confessou ser sua, tinha outro tanto expressivo da droga, 28 porções. Também tinha dinheiro, notas miúdas.

A forma como estavam dispostas as drogas, a circunstância da abordagem, imediatamente ao trato com desconhecidos, em ponto de tráfico, além de levar droga ocultada na boca e na mochila, convencem que tanto se destinavam ao tráfico como o réu estava engajado na atividade criminosa, quando da prisão.

A alegação de que a droga seria para uso próprio, não foi provada e muito menos é crível, pela citada forma em que estavam embaladas e quantidade, local onde o réu se mantinha, crescendo-se o dinheiro localizado.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

Também:

"Quem invoca um álibi, para ser absolvido, carece de cumpridamente demonstrá-lo, não bastando, para tal fim, produção de elementos de convicção que não excluam de vez a possibilidade de ter sido o autor da infração" (TJSP, AP. 53.726, Rel. Azevedo Franceschini).

A conduta é mesmo a de tráfico, não sendo necessário, para a hipótese, que o réu estivesse vendendo drogas. A acusação é pontual em alegar que trazia com ele drogas, para a mercancia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem

como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Também o fato de ser usuário de drogas não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico.

Mesmo que não houvesse sido pilhado vendendo a droga, embora quase tenha se dado, a denúncia é certa em acusá-lo de trazer com ele drogas, para tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

A quantidade da droga, embalada em porções, sua variedade, é típica de tráfico.

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age

facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Em suma, a prova não autoriza qualquer hesitação quanto ao convencimento da responsabilidade criminal do réu, mercê das condutas já delineadas, que indicam finalidade mercantil.

O réu, também, não era iniciante na prática de crimes, bem demonstrando que o cometimento de ilícitos não eram novidades em seu passado inglório.

A materialidade da infração, no tráfico, foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelo laudo de constatação (fls. 10/12), bem como pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 92/94).

Daí porque de rigor a condenação.

Fixação das penas.

Na primeira fase, observo que o réu registra condenações. Apenas uma condenação será considerada para reincidência (Processo nº 0013877-87.2005.8.26.0533 - 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP, incurso no Art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 15/08/2010, processo arquivado em 10/12/2012). A outra, embora apta para o mesmo fim, para evitar 'bis in idem' será considerada como circunstância judicial, evidenciando os seus maus antecedentes, de há muito.

Assim já se pacificou que a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas em julgado.

"O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.". (TJDF APR 10250110093863; no mesmo sentido, STJ, HC 306.222/RS).

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: 'A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial'. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

Aumento a pena base em um sexto, pelos maus antecedentes.

Na segunda, pela reincidência (Processo nº 0007705-02.2017.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 155 "caput" c/c Art. 61 "caput", II, "h" ambos do Código Penal; com trânsito em julgado para a Defesa em 18/05/2020). Exaspero a pena em mais um sexto.

Em terceira e última fase, impossível redução da pena, com base no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, porque reincidente. E a pena final, por si, impõe óbice a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis.

O réu deverá cumprir pena no regime inicial fechado, pela mesma reincidência.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar JONATAS ELIAS ANTÔNIO, às penas de seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão, regime inicial fechado e seiscentos e oitenta (680) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, I, do Código Penal.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu de custas, assistido que está por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 72).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Preso preventivamente e tendo respondido a todos os atos do processo recluso, deve assim permanecer, para garantir a eficaz aplicação da lei penal, a par de manutenção da ordem pública, rotineiramente abalada por crimes de gravidade e hediondo, como o tráfico. Interessa as suas prisões para a eficaz aplicação da lei penal.

(- HABEAS CORPUS ". ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Réu que permaneceu no cárcere durante toda a marcha processual. Condenação. Manutenção na prisão em virtude da sentença condenatória. Entendimento pretoriano prevalente. Legalidade. Ordem denegada. (TJ-MG; HC 1.0000.05.426655-6/000; Juiz de Fora; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro; Julg. 27/10/2005; DJMG 24/11/2005).

"Não fere o princípio da presunção de inocência a determinação de que o sentenciado se recolha à prisão para aguardar o julgamento de recursos que, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo" (STJ, HC 10.313 SP 5ª T., Rel. Edson Vidigal, 09.11.1999, vu DJ 13.12.1999, p. 165).

Recomende-se o réu.

P.I.C.

Americana, 1º de agosto de 2022.

ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA